

1501040-68.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... quanto ao crime de associação para o tráfico não restou demonstrada.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a desclassificação do crime de tráfico pelo crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Em caso de condenação, requereu a fixação de regime diverso do fechado e a concessão ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501040-68.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501040-68.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2327735/2021 - DEL.POL.ITAPIRA, 21727895 - DEL.POL.ITAPIRA, 2658/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS BERNARDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou DENIS BERNARDO DOS SANTOS e FÁBIO DE SOUZA PIRES (desmembrado às fls. 153/154), devidamente qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque:

a) no dia 02 de dezembro de 2021, às 9 horas, na Rua Deodato Cintra, nº 362, bloco 06, apt. 22B, Cj. Habitacional São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e união de esforços para a consecução do fim criminoso, venderam, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) porções

de droga Cannabis Sativa de Lineu, vulgarmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 34g (trinta e quatro gramas); 03 (três) porções da mesma droga, com peso aproximado de 7 g (sete gramas); 02 (dois) microtubos plásticos contendo cocaína, com o peso de 05 (cinco) gramas; e 298 (duzentas e noventa e oito) porções de maconha, com peso aproximado de 600g (seiscentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 74.

b) em data incerta, mas que perdurou até o dia 02 de dezembro de 2021, às 9 horas, no mesmo endereço acima, os acusados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Segundo a inicial, policiais militares, durante apoio ao GAECO para o cumprimento de mandados judiciais expedidos após investigação, abordaram Rodrigo Gonçalves, o qual tinha em seu poder duas porções de cocaína e três de maconha. Na sequência, o usuário indicou que havia acabado de comprar as referidas porções de droga no bloco 06, apartamento 22 B, do mesmo conjunto habitacional. Assim, os policiais militares deslocaram-se imediatamente ao local indicado e lá abordaram o acusado DENIS. Realizadas buscas no local, foram encontradas, no interior do apartamento, as porções de drogas descritas acima e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Além disso, também foi encontrado um documento pessoal pertencente ao acusado FÁBIO, sendo que DENIS confessou que estava a “tomar conta” das drogas, que são de propriedade de FÁBIO. Segundo apurado, os acusados estavam associados para a prática do comércio ilegal, sendo que FÁBIO era o proprietário das drogas e administrador do ponto de tráfico, possuindo pleno domínio dos fatos, enquanto DENIS era responsável por guardar e vender as drogas.

A prisão em flagrante do acusado DENIS foi convertida em preventiva, consoante decisão fundamentada proferida em audiência de custódia (fls. 48/51).

Às fls. 81/84, a prisão preventiva do acusado FÁBIO foi decretada.

Laudos periciais toxicológicos às fls. 111/119.

O acusado DENIS foi notificado (fls. 124) e apresentou defesa prévia (fls. 128/129).

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado FÁBIO (fls. 150).

A denúncia foi recebida aos 04 de abril de 2022 (fls. 155/157).

Citação do acusado às fls. 175.

Em audiência (fls. 195/196), foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais escritas.

A representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado somente pelo crime previsto no artigo 33, caput, Lei 11.343/2006, por entender que a autoria quanto ao crime de associação para o tráfico não restou demonstrada.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a desclassificação do crime de tráfico pelo crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Em caso de condenação, requereu a fixação de regime diverso do fechado e a concessão ao direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, a prisão cautelar

do acusado foi revista e mantida, consoante decisões de fls. 150 e 198.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 14/16, no auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, nos laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 111/122, os quais atestaram o caráter entorpecente das drogas apreendidas, bem como na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos:

O policial militar Joel Assis de Campos disse que, em apoio a uma operação realizada pelo Gaeco, no local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas, abordou a pessoa de Rodrigo, o qual trazia consigo três porções de maconha e duas de cocaína. Questionado onde havia adquirido os entorpecentes, o usuário informou que tinha comprado de uma pessoa baixa, negra, de vulgo "Faísca", no apartamento 6 B do Bloco 22. O usuário ainda relatou que havia acabado de adquirir as porções e que lá havia mais drogas guardadas. Diante disso, deslocou-se ao local e, pela janela, que se encontrava aberta, visualizou o réu deitado no sofá, com as mesmas características passadas pelo denunciante. Então, chamou-o e ele abriu a porta do imóvel, ocasião em que negou ter o vulgo de "Faísca". Questionado sobre a existência de droga no local, o réu disse que não sabia, já que não morava no local. Em diligências no interior do imóvel, foram localizadas 324 porções de maconha, idênticas às apreendidas em poder do usuário Rodrigo. Indagado sobre o que fazia no local, já que não era o morador, DENIS afirmou que era pago para olhar os entorpecentes, que pertenciam a outro rapaz. Ainda em diligência no imóvel, localizou uma carteira reservista no nome de Fábio, que, segundo DENIS, era o dono do apartamento e dos entorpecentes. Declarou que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos. Disse que também foi encontrada a quantia de R\$ 50,00 no interior do apartamento.

O policial militar Renato Luiz Santiago Filho corroborou integralmente o depoimento de seu colega de farda. Disse que estava em operação, juntamente com o Gaeco, para cumprimento de mandados no local dos fatos, quando abordou o indivíduo Rodrigo, que estava em poder de porções de maconha e cocaína. Indagado, o indivíduo informou que havia comprado os entorpecentes de "Faísca" e que, no local da compra, havia mais droga. Diante da notícia, dirigiu-se ao imóvel informado e lá viu o réu deitado no sofá, apresentando as mesmas características informadas na denúncia. Em revista pessoal, com o réu nada foi localizado. Indagado sobre a existência de drogas no local, ele disse que não tinha conhecimento. Realizada diligência no imóvel, em cima da cama foram encontrados 324 g de maconha. Questionado sobre a substância, DENIS alegou que somente guardava a substância. Em novas diligências, foi encontrado um certificado reservista no nome de Fábio, que não se encontrava no local. Segundo DENIS, ele só estava no local para guardar as drogas e "Faísca" era o dono do entorpecente. Disse que o réu afirmou que ganhava para guardar as drogas.

A testemunha Rodrigo Gonçalves disse que mora há quinze anos no condomínio onde os fatos ocorreram e conhece Fábio de vista. Conhecia as pessoas que vendiam drogas no local, mas nunca ouviu falar na pessoa de DENIS, nem nunca o viu. No dia dos fatos, quando foi abordado, trazia consigo dois flaconetes de cocaína em seu bolso, que havia comprado na entrada do Bloco 06, na frente da rua. Não indicou a pessoa nem o local onde havia comprado a droga aos policiais que o abordaram. Comprou a droga de um rapaz que tem o apelido de "China", cujo prenome é Juarez. Somente viu e conheceu DENIS na Delegacia.

Interrogado, Denis Bernardo dos Santos disse que não tem apelido e não guardava drogas. Não conhece nenhum Fábio e nada disse aos policiais no dia dos fatos. Não estava traficando. Não tinha ciência da existência de droga no local. Na época, estava saindo com uma menina e foi até o apartamento de seu amigo "Cabelinho" para ficar com ela. No dia seguinte, logo de manhã, ela foi embora e "Cabelinho" foi levar a namorada dele embora. Quando estava no imóvel esperando seu amigo voltar, os policiais lá chegaram procurando pela pessoa de "Faísca", a qual não conhece. Os policiais então passaram a revistar o imóvel, até que acharam uma sacola. Foi dormir na casa de "Cabelinho", que conhece da época da escola, mas não sabe o nome dele. Não conhece "Faísca" nem Rodrigo.

Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, tal como descrito na exordial.

A frágil versão apresentada veio desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Os depoimentos dessas testemunhas foram sempre seguros e harmônicos ao detalharem a abordagem do réu e o encontro da expressiva quantidade de maconha que ele guardava e tinha em depósito no local dos fatos, bastante conhecido como ponto de tráfico na cidade.

Os agentes ainda relataram que a apreensão do entorpecente foi realizada após a abordagem do usuário Rodrigo, que tão logo questionado sobre a procedência das porções que trazia consigo, indicou as características do vendedor, ora réu, e os dados do apartamento onde ele se encontrava.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário". (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

"(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada." (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Já a testemunha Rodrigo alterou substancialmente a versão apresentada na fase policial (fls. 12), ocasião em que descreveu ter comprado drogas do réu. Todavia, suas declarações judiciais estão dissociadas dos demais elementos probatórios coligidos aos autos, não sendo aptas a afastar a responsabilidade criminal do

acusado.

Inviável a pretendida desclassificação do delito para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, vez que o fato de o réu ser usuário não impede, por si só, o reconhecimento de traficante, quando presentes as circunstâncias acima verificadas.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, o dinheiro sem origem lícita demonstrada e os consistentes depoimentos dos policiais militares, dão a necessária certeza da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu.

Já no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, de rigor a absolvição do réu.

No caso, a organização, a pré-ordenação dolosa, a estabilidade e a permanência da sociedade criminosa, indispensáveis para a tipificação do delito capitulado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, não restaram cabalmente demonstradas.

Os policiais militares responsáveis pela prisão não forneceram informações concretas que demonstrassem o vínculo permanente e autônomo existente entre DENIS e FABIO com o intuito de comercializar entorpecentes.

A união anterior e perene não pode ser provada apenas pelas circunstâncias da prisão e da apreensão de drogas. Imprescindíveis são as provas da combinação de vontades e vínculo associativo antes do flagrante.

Assim, outra solução não resta senão a absolvição do réu da imputação do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitiva, a procedência parcial da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à fixação da reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que a quantidade de droga (mais de 600 g de maconha) apreendida com o réu são circunstâncias que, a teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, nesta primeira fase, diante da reprovabilidade de sua conduta, autorizam a exasperação da pena, de modo que a fixo em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira e derradeira fase, não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga (327 porções - 634 g de maconha) armazenada pelo réu revela que o réu se dedica ao tráfico de drogas, não fazendo jus, portanto, ao benefício idealizado apenas para traficantes de pequena monta.

Nesse sentido o C. STJ já se pronunciou:

“(...) 3. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a

atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. 4. In casu, a utilização da quantidade da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Verifica-se que o Tribunal a quo negou o benefício, concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa do tráfico, diante da quantidade da droga apreendida e circunstâncias do fato, de maneira que entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte."(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1672657/R0, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020). Grifei

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33 § 3º, do Código Penal, c.c. o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR DENIS BERNARDO DOS SANTOS, R.G. nº 45.807.546-2/SP, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; bem como ABSOLVÊ-LO da acusação da prática do crime previsto no artigo 35 da mesma Lei, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do réu, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião da decretação (fls. 48/51).

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que o réu não está preso processualmente a tempo suficiente para alcançar a detração penal.

Recomende-se o réu ao local onde se encontra.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 18/19) em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Arbitro os honorários advocatícios ao Defensor Dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29

de dezembro de 2003, observando-se ser o réu WELLISON beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA